

第47問

Xは、街中で友人Yと別れてまもなく、通行人Aの持っていたショルダーバッグをすれ違いざまに奪い取った。AがXを追って来たので、XはAの足を1、2度強く蹴って、その場に転倒させた。そのとき、異変に気付いたYが現場に駆けつけて、とっさに以上の事情を了解し、Xと一緒に、倒れているAの腹部を足蹴にして動けなくした。その後、X・Yは逃走した。Aは、大腿部骨折の大けがを負ったが、それがYの加わった後に生じたものかどうかは、わからない。

この設例におけるX・Yの罪責を論じなさい。

(一橋大学法科大学院 平成16年度)

第1 Xの罪責

Xに窃盗罪（235）、事後強盗致傷罪（238、240前段）が成立することは問題がない。前者は重い後者に吸収される。

なお、いわゆるひったくりは強盗罪（236 I）に問擬される場合もあるが、本問では、Aのショルダーバッグを奪い去った時点で反抗抑圧に足る「暴行」が行われたと見るのは無理があるだろう。

また、Yと共同正犯関係（60）になることは明らかだから、Xは暴行全体に関与しているといえ、Xに傷害結果を帰責することができる。

第2 Yの罪責

- 1 Yにも事後強盗罪が成立する可能性があるが、これは事後強盗の罪質をどのように解するのかに依存する（**論点** 事後強盗の共犯  司R1,旧H17-1）。

 212 頁  94 頁

この点については様々な学説が主張されているところであるが、身分犯説と結合犯説に大別される。一般に、身分犯説からは共犯と身分の問題となり、結合犯説からは承継的共犯の問題になると解されている。

- 2 ただし、本問では、Aの傷害結果がどの時点で生じたか不明である以上、身分犯説に立ったとしても、Aの傷害結果まで帰責するためには、承継的共犯の問題を検討しなければならない（仮に、承継的共犯の成立を肯定すれば、X単独の暴行から傷害結果が生じていたとしても、Yに帰責できる。）点に注意が必要である（**論点** 承継的共犯  司H18,H28,旧H3-1,H11-1,H17-1,H21-1）。

 129 頁  51 頁

なお、207条を適用して、致傷結果を帰責する立場も考えられないではないが、強盗罪などにまで拡張適用することについては否定的な立場が一般である（東京地判昭36.3.30など）。

答案構成

第1 Xの罪責

1 窃盗罪成立（235）

↓

2 事後強盗致傷罪（238、240前段）の成否

↓

事後強盗罪の成否

↓

「窃盗」

↓

「財物を得てこれを取り返されることを防」ぐ目的

↓

「暴行」

↓

「窃盗の機会」

↓

事後強盗罪成立

↓

致傷

↓

3 事後強盗致傷罪成立

第2 Yの罪責

1 事後強盗致傷罪の共同正犯（60）の成否

↓

「窃盗」犯人ではないYに事後強盗致傷罪の共同正犯を認めることができるか

↓

身分犯説

↓

真正身分犯説

↓

65条1項は真正身分犯に、同条2項は不真正身分犯に適用される

↓

事後強盗罪の共同正犯となる

↓

2 致傷結果まで責任を負わせることができるか

↓

承継的共同正犯の成否

↓

限定肯定説

↓

あてはめ

↓

207条も不適用

↓

- 3 事後強盗罪の共同正犯の罪責を負うに止まる

第1 Xの罪責

1 Xが通行人Aの持っていたショルダーバッグをすれ違いざまに奪い
2 取った行為については、「他人の財物を窃取した」ものとして、窃盗罪
3 (235条)が成立する。

4 2(1) 次に、AがXを追って来たので、XがAの足を1、2度強く蹴っ
5 て、その場に転倒させた行為、及びYと一緒にあって、倒れているA
6 の腹部を足蹴にして動けなくした行為について、事後強盗致傷罪(2
7 38条、240条前段)の成立が考えられる。

8 (2) まず、事後強盗罪の成否について検討するに、上記のとおり、Xは
9 「窃盗」に当たる。

10 そして、Xの暴行はAがXを追って来たのに対して行われたもので
11 あるから、「財物を得てこれを取り返されることを防」ぐために行わ
12 れたものとみることができる。

13 また、事後強盗罪も強盗の一種であるから、「暴行」は反抗を抑圧
14 するに足りるものである必要があるところ、Xの上記行為態様に鑑み
15 れば、これも認められる。

16 さらに、記述されざる構成要件要素として、「窃盗の機会」に「暴
17 行又は脅迫」が行われることを要するところ、Xが上記「暴行」を加
18 えたのは、Aから追われている状況下においてであるから、これも認
19 められる。

20 したがって、Xに事後強盗罪が成立する。

21 (3) 続いて、Aの大腿部骨折の大けがは、Yの加わった後に生じたもの
22

1

1 かどうかは明らかでないが、Yが加わった後の暴行については後述の
2 とおりXY間で共同正犯関係が成立するので、Xについては、因果関
3 係が問題なく認められる。

4 したがって、「強盗が、人を負傷させた」といえる。

5 3 以上より、Xには事後強盗致傷罪が成立する。窃盗罪は事後強盗致傷
6 罪に吸収される。

第2 Yの罪責

7 1 YがXと意を通じて、Xと共にAに対して暴行を加えた行為につい
8 て、事後強盗致傷罪の共同正犯(60条)が成立しないか問題とな
9 る。

10 (1)ア Yは「窃盗」犯人ではないから、直ちに同罪の成立を認めること
11 はできない。

12 もっとも、事後強盗行為において、「窃盗」であるXの暴行に加
13 功しているから、この点をもってYを同罪の共同正犯として処断す
14 ることはできないか。

15 イ この点について、窃盗行為は事後強盗罪の実行行為の一部である
16 と解し、暴行に加功した者の罪責について、承継的共同正犯の問題
17 として扱うこともできそうである。

18 しかし、窃盗行為に実行の着手を認めるとすると、窃盗をすれ
19 ば、全て事後強盗罪の未遂罪に問われることになりかねず、妥当で
20 ない。

21 そこで、実行行為は暴行・脅迫であり、「窃盗」の部分は身分で
22

2

あると解すべきである。このように解すれば、「窃盗が」と犯罪主体について規定した条文の文言とも整合する。

したがって、本件は共犯と身分の問題として扱うべきである。

ウ では、本罪は真正身分犯か不真正身分犯か。

この点について、窃盗の身分がない者が実行行為をすれば、暴行罪・脅迫罪となることから不真正身分犯ともいえるのである。

しかし、暴行罪・脅迫罪と事後強盗罪では保護法益が全く異なるので、本罪を暴行罪・脅迫罪の加重類型とするのは無理がある。

したがって、真正身分犯というべきである。

エ そして、65条1項の「身分によって構成すべき犯罪」、65条2項の「身分によって特に刑の軽重があるとき」という文言に着目すれば、同条1項は真正身分犯に関する規定、同条2項は不真正身分犯に関する規定であるというべきである。

さらに、65条1項の「共犯」には共同正犯を含む。非身分者も身分者を通じれば、法益侵害をすることは可能だからである。

- (2) 以上を前提として本件について検討すると、Yは事情を了解し、Xと意を通じた上で、Xと共にAに暴行を加えているから、65条1項によりXの「窃盗」の身分が連帯し、事後強盗罪の共同正犯となる。

- 2(1) もっとも、本件においては、Aの傷害結果がYの加わった後に生じたものかどうか明らかでない。そうすると、利益原則の観点（刑事訴訟法336条参照）から、Xの暴行から傷害結果が生じた場合を措定して検討しなければならない。

3

そこで、本事例のYに、X単独の暴行部分（そこから傷害結果が生じた場合）まで含めて共同正犯が成立するかが問題となる。

- (2) 共犯の処罰根拠は、自己の行為が何らかの形で、結果に対して因果性を与えた点に求められる。そうだとすれば、既に発生してしまった結果に対して因果性を遡り、処罰を肯定することはできない。

もっとも、共同正犯の場合、後行者が先行者の行為を自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用した範囲においては、その限度において共同意思の下、自己の犯罪の手段として行っているものと認められ、結果惹起に対する因果性及び正犯性を肯定できるから、共同正犯関係が成立する。

- (3) 本件では、先行する暴行（及び傷害結果）を積極的に利用する関係は認められないから、YはXが生ぜしめた結果について共同正犯として責任を負うことはない。

なお、207条の適用の有無も問題となるも、同条は立証困難の救済のため利益原則を修正して傷害結果を帰責させる例外的規定であるから、強盗の罪にまで適用範囲を拡張すべきではない。

- 3 以上より、Yは事後強盗罪の罪責を負うにとどまり、この限度でXと共同正犯となる。

以 上

4